InDret

# Libertad de expresión y conflictos civiles

## Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen y las libertades de información y expresión en la Jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de los años 1998-2000

**(II)**

**Pablo Salvador Coderch**
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

**Sonia Ramos González**
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

**Álvaro Luna Yerga**
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

**Carlos Gómez Ligüerre**
Facultad de Derecho
Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, octubre de 2001

www.indret.com

*Sumario*


- Más allá de la libertad de expresión: conflictos civiles, derechos individuales y conciencia colectiva
- STS, 1ª, 8.3.1999. Hijos de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió" y otros
    1. El caso concreto y su resolución judicial
    2. La dificultad de un juicio a la Historia
- STS, 1ª, 2.6.2000. Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza y otros
- Tabla de sentencias citadas
- Bibliografía

- ***Más allá de la libertad de expresión: conflictos civiles, libertad individual y conciencia colectiva***

Tanto la libertad de difundir información veraz como la de expresar ideas y opiniones posibilitan el desarrollo del conocimiento y el debate político, pero ni la una ni la otra bastan por sí solas para convertir al enemigo en rival, mucho menos en amigo. De hecho, una de las primeras víctimas de todo conflicto armado suele ser la verdad -toda guerra se basa en el engaño, escribió Sun Tzu- y, durante su transcurso, la expresión de las ideas colapsa en propaganda.

Hace ya casi una generación que venimos publicando reseñas y comentarios a los desarrollos jurisprudenciales del derecho español sobre honor y libertad de expresión (Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1990; Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1996; Pablo SALVADOR CODERCH, M.ª Teresa CASTIÑEIRA PALOU, 1997; Pablo SALVADOR CODERCH *et al.*, 1999). En esta ocasión como en otras anteriores, nuestro primer objetivo ha consistido en tratar de ***reconducir el conflicto civil a confrontación política presidida por dos principios constitucionales claros: la búsqueda sincera de la verdad y el debate franco de las ideas***. Como el lector de InDret comprobará enseguida, no es tarea fácil.

- ***STS, 1ª, 8.3.1999. Hijos de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió" y otros***

***1. El caso concreto y su resolución judicial***

La Guerra Civil (1936-1939) fue el conflicto más grave de la España contemporánea. La revisión de un episodio de aquella contienda dio ocasión a una Sentencia de nota sobre el derecho al honor cuando las informaciones presuntamente difamatorias objeto del pleito se referían a una persona fallecida.

El 27.11.1994 "TV3", primer canal de la televisión pública catalana, había emitido un documental titulado "*Sumaríssim 477*" sobre el Consejo de Guerra celebrado en Burgos, en agosto de 1937, contra Manuel Carrasco i Formiguera (1890-1938), político catalán fundador y presidente de *Unió Democràtica de Catalunya*, un partido político de corte demócrata-cristiano. El juicio sumarísimo terminó con Sentencia que condenó al Sr. Carrasco a pena de muerte, que fue ejecutada el 9.4.1938.

En un momento del documental, una voz en *off* afirmaba:

> "El Tribunal va condemnar Carrasco basant-se exclusivament en el testimoni de vuit catalans residents en Burgos. Es van presentar voluntàriament davant del Jutge instructor. Tenen noms i cognoms: José Ribas Seba, cap de la Falange a Catalunya,

José Mª Fontana, falangista, Antonio Martínez Tomás, periodista, José Bru Jardí, periodista, Diego Ramírez Pastor, periodista, Carlos Trias Bertran, advocat, Josep Lluch Bonastre, advocat, Enrique Najés de Duran, advocat. No van tenir compassió, Carrasco era 'rojo y era separatista'. La defensa els va denominar testimonis fantasmes, ressentits, propagadors de rumors".

*"El Tribunal condenó a Carrasco basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes residentes en Burgos. Se presentaron voluntariamente ante el Juez instructor. Tienen nombres y apellidos: José Ribas Seba, jefe de Falange en Cataluña, José Mª Fontana, falangista, Antonio Martínez Tomás, periodista, José Bru Jardí, periodista, Diego Ramírez Pastor, periodista, Carlos Trías Bertrán, abogado, Josep Lluch Bonastre, abogado, Enrique Najés de Durán, abogado. No tuvieron compasión, Carrasco era rojo y era separatista. La defensa los denominó testigos fantasma, resentidos, propagadores de rumores".*

Al final del documental, aparecía un texto sobreescrito que decía:

"Tots els testimonis de càrrec que van declarar contra Carrasco van ocupar alts càrrecs a l'Administració i la premsa franquista des de 1940".

*"Todos los testigos de cargo que declararon contra Carrasco ocuparon altos cargos en la Administración y la prensa franquista desde 1940".*

Los actores, hijos todos ellos del Sr. Carlos Trías Bertrán († 1969), una de las personas nombradas como testigos en el documental, demandaron a la autora del reportaje, a "Televisió de Catalunya, SA" y a la "Corporació Catalana de Ràdio i Televisió", solicitaron la declaración de la existencia de una intromisión ilegítima contra el honor del Sr. Carlos Trías Bertrán y reclamaron una indemnización, a determinar en ejecución de sentencia, así como la publicación de la sentencia y la supresión de determinadas frases e imágenes del reportaje.

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1/1982) ampara la protección del honor, la intimidad y la imagen como valores de la personalidad, más allá de la muerte de una persona y, en este sentido, el art. 4 LO 1/1982 regula la legitimación activa para interponer una acción de protección civil de los valores de la personalidad del fallecido. Se establece un orden de prelación que atiende, en primer lugar, a la voluntad del titular del derecho, y sólo en el caso de que ésta no conste, se concede legitimación a los familiares -cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos- y, residualmente, al Ministerio Fiscal (María E. ROVIRA SUERIO, 1999, págs. 280 y ss.).

La SJPI nº 13 de Barcelona (20.12.1996) estimó íntegramente la demanda, declaró la existencia de una intromisión ilegítima cometida por los demandados contra el honor del Sr. Trías Bertrán y les condenó a publicar a su costa la sentencia condenatoria, a suprimir en todas las copias del documental el texto arriba citado, a suprimir igualmente de todas las copias del documental el texto sobreescrito también citado y, en particular, a pagar una indemnización nominal –puramente simbólica- por importe de 5 pesetas, unos 3 céntimos de euro, así como al pago de las costas.

Los demandados recurrieron en apelación, pero la SAP de Barcelona (Sección 16ª, 17.11.1997) confirmó la Sentencia del Juzgado. En su posterior recurso de casación, los demandados alegaron la infracción de los arts. 7.7 LO 1/1982 y el art. 20.1 CE, así como la jurisprudencia que los desarrolla (SSTC, 4ª, 21.1.1988; 1ª, 12.11.1990 y SSTS, 1ª, 13.10.1998 y 5.2.1998). El Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia de instancia y desestimó la demanda, pues entendió que se habían narrado hechos históricos sustancialmente veraces y de relevancia pública junto con opiniones o juicios de valor:

> "[R]elevancia pública e interés general lo tiene el hecho histórico de la pre-guerra y parte de la guerra civil que se explica en el reportaje (...). La veracidad también es indiscutible. El hecho esencial es que don Carlos Trías Bertrán fue testigo de cargo -él y otros catalanes- en un Consejo de Guerra, sumarísimo, cuyo acusado era el político catalán don Manuel Carrasco i Formiguera. Y, como recoge la Sentencia de instancia, no parece probable que, siendo abogado, desconociese las consecuencias que una acusación de esta naturaleza en aquel lugar y momento comportaba (...).
>
> Se emplean dos adjetivos, 'exclusivamente' y 'voluntariamente', cuya veracidad hay que examinar. En el reportaje se dice que 'el Tribunal condenó a Carrasco basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes...' y, ciertamente, la sentencia no dice tal cosa; pero tampoco dice lo contrario; la sentencia que condena a muerte al acusado no expresa hechos concretos que motivan una pena de muerte, sino posiciones políticas; no enjuició unos hechos, sino una conducta y una opinión política y por ellas fue ejecutado; como recoge la sentencia de instancia, se fusilaba a un símbolo, 'Carrasco lo es todo: es Cataluña y es la República'; por tanto, no se puede decir que fue condenado exclusivamente por las declaraciones testificales, pero tampoco que lo fue por otras pruebas (pruebas ¿de qué?); en conclusión, el adjetivo 'exclusivamente' es un juicio de valor, una opinión (bajo la libertad de expresión), no un hecho (bajo la libertad de información si es veraz). Lo mismo ocurre con lo que se dice a continuación: 'se presentaron voluntariamente ante el Juez instructor': lo fueron tras citación judicial; no consta que fueran 'voluntariamente', pero tampoco consta que fueran 'forzadamente', ya que la citación judicial no excluye ni una ni otra y, además, como en la expresión anterior, es un juicio de valor, una opinión, no un hecho.
>
> Se dice en el reportaje que 'no tuvieron compasión' lo cual es un juicio de valor, una opinión, de quien fue uno de los testigos de cargo en un juicio sumarísimo en aquel momento histórico. Se dice asimismo que los testigos de cargo, como el padre de los demandantes, 'ocuparon altos cargos en la Administración y la prensa franquista desde 1940', lo cual es objetivamente cierto; si la parte demandante mantiene que esta afirmación se hace en relación con su actuación como testigo de cargo, sí es un juicio de valor; la afirmación del reportaje es veraz, veracidad que no cabe matizar o discutir" (F. D. 4º).

Así, para el Tribunal Supremo, la discusión sobre la veracidad de los hechos narrados versó sobre dos adverbios: el primero -***"exclusivamente"***- en la oración "el Tribunal condenó a Carrasco basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes (...)"; y el segundo -***"voluntariamente"***- en la oración "se presentaron voluntariamente ante el Juez instructor". Es sabido que los ***adverbios*** pueden clasificarse en ***nucleares*** y ***periféricos***, en función de que su supresión afecte o no al significado del resto de la oración (Ignacio BOSQUE y Violeta DEMONTE, 1999, pág. 725): "le hirió mortalmente" (nuclear); "le saludó cordialmente" (periférico). Los autores de este trabajo no son gramáticos de oficio, miembros de ningún jurado ni jueces del caso, pero coinciden modesta y mayoritariamente en considerar que, en "*Sumaríssim*", ***los adverbios eran periféricos***. Resulta, con todo, una apreciación perfectamente opinable: juzgue el lector.

## 2. *La dificultad de un juicio a la Historia*

Sea como fuere, el citado Fundamento de Derecho 4º de la Sentencia reseñada no siguió este camino, sino que disolvió la cuestión empírica sobre los hechos históricos narrados en el polémico documental reduciéndola a juicios de valor, a meras opiniones. Con ello, llevó el objeto del pleito a un debate sobre los símbolos que conforman nuestra memoria histórica. Para el Tribunal, el término "exclusivamente" es un juicio de valor, una opinión, amparada por la libertad de expresión -"se fusilaba a un símbolo" llega a decir implausiblemente el Tribunal-. El mismo procedimiento es empleado para reconducir el uso del adverbio "voluntariamente" desde el terreno de los hechos al de los juicios de valor u opiniones: en defecto de prueba sobre el carácter voluntario o forzado de la conducta en cuestión, afirmar cualquiera de ellos es "un juicio de valor, una opinión, no un hecho", dice el Tribunal. Mas, en esta ocasión, los autores de este trabajo discrepan de lo anterior: ***el desconocimiento de unos hechos no convierte a las afirmaciones sobre su ocurrencia en simples opiniones***. La falta de contrastación de una conjetura no legitima su afirmación por la misma razón que no justifica su negación. Hay juicios perplejos.

Sin embargo, fuerza es reconocer que la huida de la realidad concreta del caso enjuiciado y el replanteamiento del debate en términos simbólicos ya habían sido iniciados por los propios demandantes, quienes, en su demanda y como en parte también sucedió en el caso resuelto por la STS, 1ª, 2.6.2000, ejercitaban básicamente acciones vindicatorias de la memoria de su padre y negatorias o cuasinegatorias de la difusión ulterior de "*Sumaríssim 477*". Pretendían fundamentalmente evitar la formación de una memoria colectiva que juzgaban incorrecta. Reivindicaban la memoria de su padre fallecido, pero no estaban primariamente interesados en obtener una reparación económica. Es cierto que, como ya hemos indicado, en la demanda reclamaban una indemnización, pero cuando la Sentencia de primera instancia les concedió una indemnización exclusivamente simbólica, los actores se desinteresaron de toda cuestión resarcitoria y, en consecuencia, de todo aquello que permite dimensionar un daño indemnizable como tal –lo que el art. 139.2 de la Ley 30/1992 califica como daño "efectivo, evaluable económicamente e individualizado"-. Con ello, el

pleito ganó dimensión simbólica, a costa de las pretensiones de tutela individual, estrictamente privadas: en el planteamiento final del caso, de existir, el daño se refiere exclusivamente a la conciencia histórica de la colectividad, deviene un fenómeno exclusivamente social. Así, primero en la apelación y luego en casación, el tema de debate se alejó de la correcta aplicación de las normas que ordenan indemnizar daños causados por lesión del derecho al honor y pasó a versar sobre el sentido de la Historia que el documental pretendía narrar. Pero una vez situados en este ámbito, la discusión únicamente podía tener como objeto los hechos que sustentaban la opinión que se había decidido trasmitir sobre ellos: sólo si los hechos narrados claramente no tuvieron lugar, estaría fundada la reclamación. Pero, de ser ciertos en lo sustancial, toda opinión sobre ellos es libre y está amparada por la libertad de expresión -fuera tal vez del caso extremo en que fuera innecesariamente injuriosa-.

Cabe enjuiciar conductas, pero juzgar identidades es una perversión de la Justicia, equivale a rebajar el ordenamiento jurídico hasta dejarlo en derecho –penal, civil, constitucional- de autor, pues juzgar identidades supone que es posible pedir la condena de una persona o de un grupo de personas no por su comportamiento, sino por lo que son o fueron en algún momento de su vida. En la Guerra Civil y en su postguerra muchísimas personas murieron violentamente por lo que eran o habían sido, pero no por lo que habían hecho, ni siquiera por lo que habían dejado de hacer. La Sentencia reseñada es un ejemplo paradigmático de difícil discusión jurídica sobre identidades colectivas, o si se prefiere, sobre la memoria histórica de una comunidad, pero no sobre comportamientos individuales. "*Sumaríssim*" no es un pleito de derecho civil de daños sobre las eventuales conductas que hipotéticamente los causan, ni siquiera es un litigio sobre derechos absolutos –como lo es el derecho al honor- a verse libres de determinadas intrusiones. Antes bien, es fundamentalmente un conflicto sobre las ideas compartidas que construyen la identidad social de una comunidad y, desde este punto de vista, el problema trasciende las cuestiones individuales del derecho al honor, es decir, las relativas a la reputación y autoestima de una persona o, fallecida ésta, de sus descendientes: el objeto cabal del conflicto es el conocimiento común y compartido por un conjunto de personas que permite a cada una de ellas identificarse como miembro de una comunidad. Los demandantes discrepaban de la corrección de este conocimiento común y pretendían, literalmente, suprimirlo como un elemento de la conciencia colectiva de la comunidad. Su interés no era económico, pues no alegaban haber sufrido daños, sino que pretendían evitar lo que explicablemente entendían como una tergiversación de hechos históricos, como una imagen falseada de la realidad.

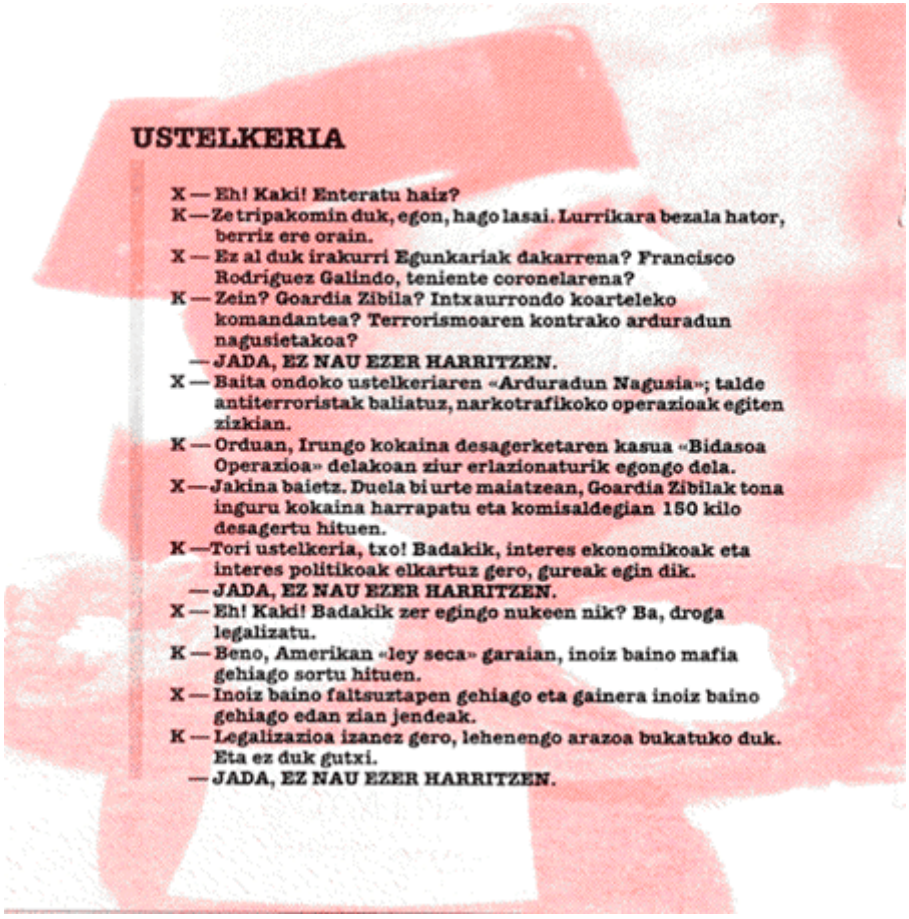
"*Sumaríssim*" es, pues, un pleito sobre ideas que se sitúa, incluso para los propios actores, fuera del ámbito propio de las pretensiones civiles de carácter resarcitorio. Sin embargo, el derecho civil y el derecho civil constitucional conocen derechos absolutos, como el derecho fundamental al honor, cuya violación podría muy bien dar lugar a acciones negatorias como la ejercitada por los demandantes en este caso. Sucede, con todo, que la base empírica de su caso resultaba probablemente endeble; el núcleo fundamental de las expresiones objeto del pleito estaba formado por opiniones, es decir, por juicios de valor amparados por la libertad de expresión –conocidamente más amplia que la libertad de información-. En

relación con esta última, todo lo que aquellas expresiones tenían de afirmaciones contrastables empíricamente se expresaba de forma lo suficientemente genérica como para resultar verdadera en lo sustancial, pues el padre de los demandantes había sido requerido como testigo de cargo, había prestado efectivamente testimonio en el proceso en cuestión y había luego ocupado cargos públicos durante los años que siguieron a la Guerra Civil. Los demandantes podrían haber escogido otro ámbito de debate para defender su posición, pero no hicieron tal cosa y resolvieron llevar a juicio un determinado fragmento de la Historia ante los Tribunales. Mas la valoración positiva o negativa de la Historia y de la imagen que las distintas generaciones de una misma comunidad deciden formarse de esa misma Historia sólo muy difícilmente pueden ser puestas objetivamente en cuestión ante un Tribunal, mucho menos cuando uno de los rasgos más frecuentes, bárbaros y conocidos de la Guerra Civil fue la aniquilación del adversario ideológico. Es cierto que hay ocasiones en que el derecho puede pretender entrar en el difícil terreno de las ideas que constituyen nuestra personalidad social y que es posible litigar contra quienes las defienden o publican, pero InDret cree que, al menos como regla de principio, ello sólo debería poder hacerse con éxito si la adecuación empírica de las imágenes históricas es claramente inexistente.

* * *

La historia no acaba con cada uno de sus capítulos: en la fecha de redacción de este trabajo, la Sentencia del Tribunal Supremo que acabamos de reseñar está pendiente de resolución del recurso de amparo, interpuesto el 13.4.1999 y que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Tiempo habrá para continuar -o modificar- las reflexiones que aquí se dejan sólo apuntadas.

- ***STS, 1ª, 2.6.2000. Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza y otros***



**USTELKERIA**

X — Eh! Kaki! Enteratu haiz?
K — Ze tripakomin duk, egon, hago lasai. Lurrikara bezala hator, berriz ere orain.
X — Ez al duk irakurri Egunkariak dakarrena? Francisco Rodríguez Galindo, teniente coronelarena?
K — Zein? Goardia Zibila? Intxaurrondo koarteleko komandantea? Terrorismoaren kontrako arduradun nagusietakoa?
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.
X — Baita ondoko ustelkeriaren «Arduradun Nagusia»; talde antiterroristak baliatuz, narkotrafikoko operazioak egiten zizkian.
K — Orduan, Irungo kokaina desagerketaren kasua «Bidasoa Operazioa» delakoan ziur erlazionaturik egongo dela.
X — Jakina baietz. Duela bi urte maiatzean, Goardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisaldegian 150 kilo desagertu hituen.
K — Tori ustelkeria, txo! Badakik, interes ekonomikoak eta interes politikoak elkartuz gero, gureak egin dik.
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.
X — Eh! Kaki! Badakik zer egingo nukeen nik? Ba, droga legalizatu.
K — Beno, Amerikan «ley seca» garaian, inoiz baino mafia gehiago sortu hituen.
X — Inoiz baino faltsuztapen gehiago eta gainera inoiz baino gehiago edan zian jendeak.
K — Legalizazioa izanez gero, lehenengo arazoa bukatuko duk. Eta ez duk gutxi.
— JADA, EZ NAU EZER HARRITZEN.

***PODREDUMBRE*** *X.- Eh! Kaki! ¿Te has enterado? K.- Qué tripa se te ha roto ahora que vienes como un terremoto, estáte tranquilo tío X.- ¿No has leído qué trae el Egunkaria? ¿Lo del teniente coronel Francisco Rodríguez Galindo? K.- ¿Quién? ¿El Guardia Civil? ¿El comandante del cuartel de Intxaurrondo*[1]*? ¿Uno de los principales responsables de la lucha antiterrorismo? X.- Y además el principal responsable de la podredumbre que te voy a contar ahora. Sirviéndose de los grupos antiterroristas, realizaba operaciones de narcotráfico. K.- Entonces, el caso de la desaparición de la coca en Irún en la llamada operación Bidasoa estará también relacionado. X.- ¡Pues claro! Hace dos años en mayo, la Guardia Civil pilló una tonelada de coca y en la comisaría desaparecieron 150 kilos. K.- ¡Vaya jodida mierda! Ya sabes, como más los intereses políticos y los intereses económicos, la hemos cagado. X.- ¡Eh, Kaki! Sabes lo que haría yo... legalizar la droga. K.- Bueno, en tiempos de la Ley Seca, en América, salieron más mafias que nunca. X.- Muchas más adulteraciones y encima bebió más que nunca. K.- Hombre, si se legalizara, el primer problema estaría solucionado y no es poco. Ya no me alucina nada.*[2]

[1] El Sr. Enrique Rodríguez Galindo, entonces teniente coronel de la Guardia Civil, estuvo al mando del cuartel de Intxaurrondo, la 513 comandancia de la Guardia Civil, como jefe del acuartelamiento, desde 1983 a 1995.
[2] Traducción de la letra de la canción según consta en la STS, 1ª, 2.6.2000.

*Negu Gorriak*, un conocido grupo musical vasco, incluyó *Ustelkeria* (Podredumbre) en su segundo disco, *Gure Jarrera* (Nuestra Posición), editado en 1991 por *Esan Ozenki Records*.

El actor, Sr. Enrique Rodríguez Galindo, formuló demanda de protección del derecho al honor contra varios componentes del grupo *Negu Gorriak*, *Esan Ozenki Records* y otros. Las pretensiones del actor eran de doble naturaleza. Por un lado, ejercitaba una acción cuasi negatoria en virtud de la cual pedía que se abstuvieran de realizar intromisiones semejantes en el futuro, de incluir la canción *Ustelkeria* en sucesivas reediciones discográficas y de interpretarla en cualesquiera de sus actuaciones, y, en segundo término, ejercitaba una acción resarcitoria y pedía una indemnización de 90.151,82 €, además de los intereses legales y las costas.

La demanda fue desestimada en primera instancia por la SJPI nº 4 de San Sebastián, 3.1.1994, y estimada en lo sustancial en apelación por la SAP de San Sebastián, Sección 1ª, 25.5.1995.

En el cuarto motivo de su recurso de casación, que resultó acogido por el Tribunal Supremo, los demandados habían alegado la violación del art. 1139.1 del Código Civil (CC) en relación con los arts. 1151 y 1137 CC, así como de la doctrina jurisprudencial sobre litisconsorcio pasivo necesario, pues la demanda no se había dirigido contra Miguel Ángel C. L., uno de los coautores de la letra y música de la canción. En el Fundamento de Derecho 4º de la Sentencia, el Tribunal Supremo dijo:

> "De acuerdo con la documentación aportada a los autos, expedida por la Sociedad General de Autores de España (folios 685 a 703 de los autos de primera instancia), las personas que figuran como autores de la letra en la obra 'Ustelkeria' son Fermín M. U., Íñigo M. U. y Miguel Ángel C. L., y como autores de la música de esa obra, los tres citados e Ignacio A. B. Nos encontramos, por tanto, ante una obra resultado de la intervención coetánea de varias personas con la finalidad de lograr una única obra, cuya titularidad corresponde a todas ellas; se trata de una obra de colaboración de aquellas a que se refiere el art. 7.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto en su texto de 11 de noviembre de 1987 como del vigente Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, según el cual 'Los derechos de una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos', rigiéndose esta situación de comunidad en lo no previsto en esta Ley, por las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes (art. 7.4. de dicha Ley), es decir, por los arts. 392 y siguientes del Código".
>
> "[Las] pretensiones [del actor acogidas por] la sentencia recurrida, afectan directamente al derecho moral y a los derechos de explotación de los autores de la obra que, prácticamente, quedan anulados o extinguidos, autores entre los que se encuentra don Miguel Angel C. L. quien resulta privado de esos derechos como autor del texto de la canción sin haber sido oído. No es aplicable al caso la doctrina

> emanada de esta sala en procedimientos de esta clase que establece la responsabilidad solidaria entre autor, director de la publicación y empresa editora que niega la falta de litisconsorcio pasivo necesario en caso de que no se demande a todos ellos, precisamente por esa razón de solidaridad derivada de una conjunción de conductas diferenciadas de distinta naturaleza imputable a cada uno de ellos. En el caso, se está ante una acción única imputable a varios autores (la creación del texto denunciado), en la que no pueden establecerse, a estos efectos, grados de participación por ser resultado de un trabajo coordinado a ese fin. En conclusión, ha de afirmarse que debió ser llamado al proceso Miguel Ángel C. L.".

La Sentencia de la Sala 1ª es encomiable. Al margen del sentido material del fallo, el Tribunal reconduce hábilmente los términos de un conflicto civil intratable al ámbito de un pulcro debate técnico-jurídico: de haber ejercitado el actor únicamente pretensiones estrictamente resarcitorias podría defenderse la improcedencia de aplicar la doctrina del litisconsorcio pasivo necesario, pues, aunque con vacilaciones, hace muchos años que la Sala 1ª del Tribunal Supremo entiende que la responsabilidad de los cocausantes de un mismo daño es solidaria o lo es, al menos, cuando no puede determinarse el grado de contribución de cada cual a la producción del daño y que, por tanto, hay que aplicar el art. 1144 CC, según el cual "[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente".

> La reciente STS, 1ª, 3.11.1999 constituye una excepción a esta línea jurisprudencial. En el caso, una comunidad de propietarios de chalés adosados demandó a la constructora, "Selecciones Inversoras, SA" ("Selesor") por deterioros en las viviendas. La actora reclamaba 6.759 € en concepto de reparaciones urgentes que había llevado a cabo ante la pasividad de la constructora y la realización de las obras de consolidación definitiva de los inmuebles, necesarias para subsanar una serie de deficiencias constructivas que éstos presentaban. La SJPI nº 48 de Madrid (7.7.1992) estimó íntegramente la demanda. La AP de Madrid (17.1.1995) revocó parcialmente la sentencia de instancia, absolvió a "Selesor" del pago de la cantidad reclamada y declaró la responsabilidad solidaria de la constructora y los arquitectos respecto de la obligación de hacer. El TS estimó el recurso de casación interpuesto por "Selesor", afirmó la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, casó y anuló las sentencias de instancia y anuló las actuaciones:
>
> "Las derivaciones de la solidaridad no son correctas. Sí lo es su establecimiento; para el caso de no poder individualizarse la parte de daño ocasionado por cada interviniente. Pero es una solidaridad que 'nace' de la Sentencia, originada por razones de protección al dañado. Ello exige que hayan sido declarados en la Sentencia como 'responsables' varios sujetos, lo que comporta necesariamente que hayan intervenido como partes en el proceso. En modo alguno se puede declarar la responsabilidad de quien no ha sido llamado al proceso, con la consiguiente acción de repetición contra él del condenado que paga por entero (art. 1145) (...). De la solidaridad nacida de la Sentencia no se puede deducir que ya en el momento de demandar rigen las reglas de la solidaridad, que es lo que hace la Sentencia recurrida, siguiendo una orientación mayoritaria en la Jurisprudencia de esta Sala". (F. D. 4º).

Sin embargo, la parte más sustancial de la demanda del actor estaba integrada por acciones cuasinegatorias, es decir, por pretensiones típicamente reales, configuradas a partir del modelo del derecho de propiedad y de otros derechos absolutos, como es el caso del

derecho fundamental al honor, cuya protección nunca se ha limitado a acciones resarcitorias. De ahí que al Tribunal le resultara relativamente sencillo razonar desde la comunidad de propietarios al derecho de autor y al derecho moral de autor y aplique al caso la vieja y buena doctrina, según la cual las sentencias conseguidas contra un comunero no perjudican a los demás (José María MIQUEL GONZÁLEZ, 1991, pág. 1077) y es necesario demandar a todos los comuneros, dando lugar al llamado litisconsorcio pasivo necesario (José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.*, 2001, pág. 353; Angel M. LÓPEZ y LÓPEZ y Vicente L. MONTÉS PENADÉS (coords.) *et al.*, 1994., pág. 395; Jorge CAFFARENA LAPORTA, 1991, pág. 122; Vicente GUILARTE ZAPATERO, 1980).

Llegados a este punto, el lector de InDret podría pensar que, en el caso, el Tribunal Supremo rehuyó resolver el conflicto material refugiándose en cuestiones procesales, pues no dio respuesta alguna a la pregunta de fondo: ¿qué decir de la "podredumbre", de las "operaciones de narcotráfico" imputadas por los demandados al actor? De hecho y durante el periodo considerado, el Tribunal Supremo tuvo hasta tres ocasiones de ofrecer respuestas a aquella pregunta. No desaprovechó ninguna de ellas. El lector interesado en conocer las respuestas y razones del TS puede consultarlas en el anexo.

- ***Tabla de sentencias citadas***

### *Sentencias del Tribunal Supremo*

| *Sala y Fecha* | *Ar.* | *Magistrado Ponente* | *Partes* |
|---|---|---|---|
| 1ª, 13.6.1987 | 9964 | Jaime Santos Briz | Josefa R. F. y otros c. Fernando J. S. y otros |
| 1ª, 5.2.1998 | 405 | Ignacio Sierra Gil de la Cuesta | Enrique Múgica Herzog c. "Silex Media" y otros |
| 1ª, 13.10.1998 | 8069 | Alfonso Villagómez Rodil | Emilio O. P. c. "Difusora de Información Periódica, SA" y otros |
| 1ª, 8.3.1999 | 1407 | Xavier O'Callaghan Muñoz | Hijos de Carlos Trías Bertrán c. "Corporació Catalana de Radio i Televisió" y otros |
| 1ª, 3.11.1999 | 9043 | Antonio Gullón Ballesteros | Comunidad de Propietarios c. "Selesor, SA" |
| 1ª, 2.6.2000 | 3998 | Pedro González Poveda | Enrique Rodríguez Galindo c. Fermín Muguruza y otros |

### *Sentencias del Tribunal Constitucional*

| *Sala y Fecha* | *Ar.* | *Magistrado Ponente* | *Partes* |
|---|---|---|---|
| 1ª, 21.1.1988 | 6 | Luis Díez-Picazo y Ponce de León | Javier Crespo Martínez c. STS, 4ª, 22.11.1986 |
| 1ª, 12.11.1990 | 171 | Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer | Juan Luis Cebrián Echarri y «Promotora de Informaciones Sociedad Anónima» c. STS, 1ª, 7.3.1988 |

- ***Bibliografía***

Ignacio BOSQUE y Violeta DEMONTE (dirs.). *Gramática descriptiva de la Lengua Española,* Espasa, Madrid, 1999.

Jorge CAFFARENA LAPORTA, Comentario a los arts. 1139 y ss. CC, en Cándido Paz Ares Rodríguez, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Rodrigo Bercovitz y Pablo Salvador Coderch (dirs.), *Comentario del Código Civil,* Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.

Vicente GUILARTE ZAPATERO, Comentario a los arts. 1139 y ss. CC, en Manuel Albaladejo (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo XV, Volumen II, Edersa, Madrid, 1980.

José Luis LACRUZ BERDEJO *et al.* Elementos de Derecho Civil. Tomo III. Volúmen Segundo. Derechos reales. Derechos reales limitados. Situaciones de cotitularidad, Dykinson, Madrid, 2001.

Angel M. LÓPEZ y LÓPEZ y Vicente L. MONTÉS PENADÉS (coords.) *et al. Derechos reales y derecho inmobiliario registral*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994.

José María MIQUEL GONZÁLEZ, Comentario a los arts. 394 y ss. CC, en Cándido Paz Ares Rodríguez, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Rodrigo Bercovitz y Pablo Salvador Coderch (dirs.), *Comentario del Código Civil,* Tomo II, 2ª ed., Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

María E. ROVIRA SUERIO. *La responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen*, Cedecs, Barcelona, 1999.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al.¿Qué es difamar? Libelo contra la ley del libelo*, Madrid, Civitas. 1987.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al. El mercado de las ideas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al.* "Honor y libertad de expresión en 1995. Una reseña jurisprudencial", *Derecho Privado y Constitución*, nº 10, septiembre-diciembre 1996.

Pablo SALVADOR CODERCH y M.ª Teresa CASTIÑEIRA PALOU. *Prevenir y castigar. Libertad de información y expresión, tutela del honor y funciones del derecho de daños*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

Pablo SALVADOR CODERCH *et al.* "Honor, intimidad personal y familiar y derecho a la propia imagen en la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo del bienio 1996-1997", *Revista del Poder Judicial*, Consejo General del Poder Judicial, nº 53, enero-marzo 1999, págs. 455 y ss.

# ANEXO I

## Derecho al honor e imputaciones de corrupción a un alto mando de la Guardia Civil

Los tres casos a los que se hace mención en el cuerpo del artículo y que entraron en el fondo de la imputación de "podredumbre" fueron los siguientes:

a) **STS, 1ª, 15.1.1999**: "Diario 16" había publicado, entre el 14.11.1990 y 15.3.1991, 11 artículos sobre un informe del Fiscal de la AP de Guipúzcoa, Luis Navajas, que investigaba la posible existencia de una banda de narcotraficantes entre cuyos componentes podría encontrarse Enrique Rodríguez Galindo. Éste reclamó de los periodistas y de la sociedad editora del periódico una indemnización de 50.000.000 ptas. (300.506,052 €) y la publicación de la sentencia condenatoria. La demanda fue rechazada en ambas instancias y el TS declaró no haber lugar al recurso: las informaciones publicadas eran sustancialmente verdaderas, de interés general y reproducían en lo sustancial noticias publicadas por el Diario "*Egin*" en una edición anterior (F. D. 6º).

b) **STS, 1ª, 18.4.2000:** "*Egin*", en 6 artículos publicados entre el 15.11.1990 y el 17.1.1991, se había referido al mencionado informe y a la presunta implicación del Sr. Rodríguez Galindo en los hechos narrados. Éste demandó a dos periodistas, al director y a la editora de "*Egin*" 30.000.000 ptas. (180.303,631 €) y la publicación de la sentencia condenatoria. El JPI nº 2 de Bilbao (3.3.1993) estimó parcialmente la demanda y condenó a los demandados a pagar una indemnización de 10.000.000 ptas. (60.101,21 €). En apelación, la SAP de Bilbao (Sección 4ª, 3.4.1995) absolvió a los demandados. El TS rechazó el recurso de casación del actor: los demandados se habían limitado a reproducir el contenido sustancial de la información publicada por "Diario 16" antes referida (F. D. 3º). Obsérvese que la sentencia de 1999 afirma que "Diario 16" reprodujo informaciones publicadas por *Egin* ("el Tribunal *a quo* estableció que el 'Diario 16' se limita a informar de lo publicado por el periódico 'Egin', el día anterior, y transcribe esa información literalmente de la que no se aparta ni un ápice, sin apostillarla ni comentarla, y dejando, en todo momento clara y reiterada constancia de estar reproduciendo la información proporcionada por otro periódico", F. D. 6º) y la del año 2000 dice que *Egin* reprodujo informaciones publicadas anteriormente por Diario 16 ("la información en cuestión ... se limita a reproducir la informaciones ... tal y como lo publicaba su fuente de información, esto es, el periódico 'Diario 16', sin añadir comentario o valoración alguno", F. D. 2º).

**c)** STS, 1ª, 13.10.2000: En el libro titulado "La red Galindo", editado por la demandada "Txalaparta" y del que era autor el codemandado José Benigno R. R. se narraban noveladamente los hechos objeto de los dos casos mencionados. El Sr. Rodríguez Galindo reclamó en su demanda una indemnización de 60.000.000 ptas. (360.607,262 €), la publicación de la sentencia y que los demandados se abstuvieran en el futuro de realizar intromisiones semejantes. Las sentencias de instancias concedieron y el TS convalidó una indemnización por importe de 5.000.000 ptas. (30.050,61 €). En esta ocasión, el TS coincidió con la Audiencia en que el contenido de la información no era veraz (F. D. 3º).

De las tres últimas sentencias reseñadas, únicos antecedentes a los que InDret ha tenido acceso para reseñarlas (y, de derecho, los únicos relevantes para formar jurisprudencia) no se desprende un criterio común de resolución. Hay, con todo, algunos elementos de juicio claros: en primer lugar, resalta la deferencia que todo tribunal de casación ha de manifestar en relación con los hechos que la sentencia de segunda instancia hubiera declarado probados; en segundo término, la diferencia del sentido de la resolución entre los dos primeros casos, que se refieren a reportajes periodísticos, y el tercero, cuyo objeto es un libro, quizás deriva de la exigencia normativa en virtud de la cual se exige al autor de un libro más rigor del que se exige al periodista, mas ni el TS afirma expresamente tal cosa ni probablemente sería razonable establecer un criterio general en ese sentido, pues es arbitrario aplicar criterios distintos a un mismo contenido informativo por la simple circunstancia de que aparezca encuadernado; en tercer lugar, tal vez el número y entidad de las afirmaciones no contrastadas incluidas en el libro fuera muy superior al de las que conformaban los reportajes objeto de las dos primeras sentencias, o acaso y por último, el confesado propósito de novelar la realidad pudo entenderse por el TS como una inaceptable licencia para propalar falsedades.

En el período considerado, otras Sentencias han resuelto casos de imputaciones de corrupción y tráfico de influencias: se acusa a la actor de haber obtenido un puesto en el Ministerio de Hacienda gracias a Alfonso Guerra (STS, 1ª, 12.6.1998); se acusa al actor de facilitar, desde su cargo de Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, información reservada a Jesús de Polanco (STS, 1ª, 22.6.1998); reportaje sobre un escándalo urbanístico en el municipio de Llanes en que se implicaba a una serie de personas en una trama para financiar ilegalmente al PSOE (STS, 1ª, 30.7.1998); se involucra a un miembro de la Benemérita en actividades de narcotráfico (STS, 1ª, 25.11.1998); se acusa a un juez de prevaricación (STS, 1ª, 16.2.1999); se implica al Alcalde de Algeciras en un fraude urbanístico de 120.202,420 €. (STS, 1ª, 23.3.1999); se acusa de corrupción a miembros de una asociación (STS, 1ª, 5.7.1999); se acusa a un alcalde de fraude y prevaricación en relación con la aprobación y realización de ciertos planes urbanísticos (STS, 1ª, 16.7.1999); se acusa a un Subdirector General del Ministerio de Asuntos Exteriores del cobro de comisiones en la compra de material informático a una empresa alemana (STS, 1ª, 31.12.1999); se acusa a un oficial de juzgado de cohecho y de practicar el sistema de "astillas" (STS, 1ª, 27.5.2000); se acusa a un Concejal de narcotráfico (STS, 1ª, 24.6.2000); imputaciones de corrupción respecto a la recalificación de unos terrenos (STS, 1ª, 8.7.2000); se acusa de "compincheo" y "favoritismo" a los actores en relación con las obras de reforma del edificio "Coliseo" de Eibar y del proceso municipal de contratación (STS, 1ª, 13.10.2000).

# ANEXO II

## Contraterrorismo y guerra sucia: noticia de un proceso pendiente de finalización

La STS, 2ª, de 20.7.2001, que confirma en lo sustancial la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, de 26.4.2000, condenó al señor Enrique Rodríguez Galindo junto con otras personas por dos delitos de asesinato y detención ilegal. En el caso, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala habían sido detenidos en Bayona el 15.10.1983 y muertos por disparos en la nuca y enterrados en cal viva en Busot (Alicante) pocos días después.

La mencionada sentencia del Tribunal Supremo es una más de las que han abordado el episodio histórico de la formación, amparada por altos cargos del gobierno español, del denominado "Grupos Antiterroristas de Liberación". El GAL era una banda armada, ilegalmente constituida para combatir el terrorismo exactamente con sus mismas armas. La STS, 2ª, 29.7.1998, que resuelve el llamado "Caso Marey", condenó a varios de sus componentes, entre los que no se encontraba el Sr. Enrique Rodríguez Galindo, por los delitos de malversación de caudales públicos, secuestro y detención ilegal de Segundo Marey, un empresario francés al que confundieron con un miembro de la banda terrorista ETA.